

1501612-18.2020.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... pelo Ministério Público nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes - cuja pena mínima é superior a 4 anos -, em razão do não preenchimento de um dos requisitos objetivos do art. 28-A, caput, do CPP.

2. É inviável a análise acerca do reconhecimento do tráfico privilegiado e da quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

2ª Vara

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Várzea Paulista - SP

Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

1501612-18.2020.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501612-18.2020.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELVIN LUAN DOS SANTOS BEZERRA

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. KELVIN LUAN DOS SANTOS BEZERRA, qualificado à fl. 15, está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 02 de agosto de 2020, por volta das 14h31min, na Rua França, 49, Vila Real, Várzea Paulista, trazia consigo, para o fim de tráfico e para a entrega ao consumo de terceiros, 34 (trinta e quatro) porções individualizadas de Cannabis Sativa L, 40 (quarenta) porções individualizadas de cocaína apresentadas na modalidade de pedras de crack, e 25 (vinte e cinco) porções individualizadas de cocaína em pó, substâncias essas entorpecentes e que causam dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Denúncia oferecida em 12 de agosto de 2020 (fls. 79/81) e recebida em 17 de agosto de 2020 (fls. 85/86).

Devidamente citado, Kelvin apresentou a resposta à acusação (certidão de fl. 111 e fls. 98/107).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 119).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório de Kelvin (fls. 138,141 e 142/143).

Em memoriais escritos, a representante do Ministério Público requereu seja Kelvin condenado nos exatos termos da denúncia (fls. 139/140)
O defensor requereu seja Kelvin absolvido (fls. 139/140).

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

Do acordo de não persecução penal

O art. 28-A, caput, e § 1º do Código de Processo Penal, dispõe que:

"Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

...

1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto."

O art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 dispõe que:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

É possível, em tese, considerar que seria aplicável o art. 28-A do Código de Processo Penal ao "tráfico privilegiado".

A proposta deve ser formulada pelo Ministério Público, titular da ação penal, que, no presente caso, entende inaplicável a causa de diminuição de pena. A representante do Parquet, não enquadrando a conduta de Kelvin naquela prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Em memoriais, reiterou que entende ser descabida a aplicação da causa de diminuição de pena.

Dito isso, não há por que determinar que a representante do Ministério Público manifeste-se sobre a possibilidade de ser ofertado ao réu o acordo de não persecução penal.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. AUSÊNCIA REQUISITO OBJETIVO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REAVALIAÇÃO. PRAZO DE 90 DIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. É incabível o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes - cuja pena mínima é superior a 4 anos -, em razão do não preenchimento de um dos requisitos objetivos do art. 28-A, caput, do CPP.

2. É inviável a análise acerca do reconhecimento do tráfico privilegiado e da quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado sobre a condenação final.

...

6. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC 145.629/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021 - g.n.).

Ultrapassada essa questão, passo a analisar o mérito.

A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou cabalmente comprovada com o auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, com o laudo

constatação provisória de fls. 13/14, que resultou positivo para as substâncias Cannabis Sativa L e cocaína, e com o exame químico toxicológico de fls. 96/97, igualmente positivo para as substâncias mencionadas.

A autoria é certa.

Em Juízo, Kelvin declarou que no dia dos fatos "eu estava nesse ponto vendendo. Nesse momento, eles dobraram a esquina e eu empreendi fuga. O dinheiro era da venda. Eu estava vendendo entorpecentes naquele local "há um mês e pouco". Eu não conhecia os policiais militares. Na época dos fatos eu estava trabalhando como montador de móveis, com pintura de prédios e em uma mecânica. Eu fazia alguns bicos. Eu não estou trabalhando. Eu nunca fui processado. Eu nunca "mais tive envolvimento na prática de ilícitos após o ocorrido". Eu parei de estudar no 8º ano - 7ª série. Estou "aguardando os meus papeis" para poder retomar os estudos e para poder "arrumar um emprego". Eu não sei dizer "em qual ano eu parei de estudar".

A versão apresentada por Kelvin em Juízo não destoa da prova coligida.

Rodrigo, policial militar, declarou "recordo-me vagamente dos fatos. Eu li o BO/PC. Consta do BO/PC que nós estávamos em patrulhamento pelo local que é conhecido como ponto de venda de drogas. O réu visualizou a viatura e empreendeu fuga. Ele não ficou fora de nosso campo de visão. Nós conseguimos capturar o réu. Nós encontramos uma sacola na cintura do réu. Havia drogas e uma quantia em dinheiro dentro dessa sacola. O réu "já assumiu que estava vendendo entorpecentes no local". A sacola "estava presa entre o corpo, a cueca e a vestimenta". O réu disse que a quantia em dinheiro era proveniente da venda das drogas. Ele disse que já tinha sido preso por envolvimento anterior com o tráfico de entorpecentes. O réu estava parado na esquina antes de correr. Eu não lembro se o réu estava em pé. As drogas estavam embaladas para a venda."

Diego, policial militar, contou que no dia dos fatos "nós estávamos em patrulhamento pela Rua Franca, local conhecido como ponto de venda de drogas, no momento em que um indivíduo suspeito empreendeu fuga e entrou na viela. Nós conseguimos captura-lo na viela. Nós encontramos um invólucro plástico contendo drogas e dinheiro na cintura desse indivíduo. Ele admitiu que estava no local vendendo entorpecentes. O réu "olhou a viatura e empreendeu fuga". Eu não lembro se nós apreendemos um aparelho de telefone celular. Todas as drogas estavam embaladas para a venda. O dinheiro estava dentro da sacola. O dinheiro era proveniente da venda das drogas."

Pois bem.

Os policiais militares relataram como se deu a abordagem de Kelvin e a apreensão dos entorpecentes e da quantia em dinheiro.

Kelvin correu no momento em que notou a aproximação da viatura, conduta esperada somente de quem está envolvido com a prática de ilícito. As drogas estavam com o réu, que prontamente admitiu envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

A versão apresentada pelos policiais militares não é suspeita, pois eles não estão impedidos de prestar depoimento em Juízo e o fazem como qualquer testemunha.

Somente pode ser desconsiderada se contrariada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que não se verificou no presente caso.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Relª. Minª. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6ª Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).

O relato dos policiais militares não destoa da versão apresentada por Kelvin.

Destarte, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade, a condenação de Kelvin pela prática do crime de tráfico de entorpecentes é de rigor.

Passo a dosar a pena de Kelvin.

Em consonância com a diretriz estabelecida no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal uma vez que a culpabilidade, a conduta social, a

personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não indicam a necessidade de majoração da pena-base nesta primeira fase de fixação. A pena-base é calculada em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Kelvin não ostenta antecedentes infracionais, como argumentou a representante do Parquet. Conforme pesquisa efetuada nessa data, pude apurar que os autos que tramitaram sob o número 1501735-08.2019.8.26.0655 foram arquivados a pedido do Ministério Público. Kelvin não foi representado por envolvimento na prática do ato infracional de tráfico de entorpecentes.

Mas não é só.

O art. 42 da Lei nº 11.343/06 dispõe que:

"Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

Kelvin trazia consigo 34 (trinta e quatro) porções de Cannabis Sativa L - 72g (setenta e dois gramas), 40 (quarenta) porções de cocaína apresentadas na modalidade de pedras de crack - 30g (trinta gramas), e 25 (vinte e cinco) porções de cocaína em pó - 46g (quarenta e seis gramas).

O aumento referido no art. 42 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a apreensão de uma quantidade expressiva de entorpecentes com alto poder viciante.

No caso, Kelvin trazia consigo 30 gramas de crack, entorpecente que, pela natureza, poderia autorizar a majoração da pena-base.

É de se ver, no entanto, que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, de modo que não parece razoável aumentar a pena nessa primeira fase de fixação.

Deve ser considerada a incidência das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, "d", do Código Penal, visto que o agente é menor de 21 anos e confessou a prática desse crime. Contudo, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de proceder à diminuição nessa segunda fase, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça a dispor que:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, deve ser aplicada, pois o réu é primário e ostenta bons antecedentes. Não há razão para que a diminuição não se dê no máximo previsto. A pena fica fixada, portanto, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

A despeito da gravidade do crime praticado e mesmo se considerado que o acusado trazia consigo entorpecentes de alto poder viciante, entendo que é possível substituir a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito indicadas no art. 43 do Código Penal.

Explico.

Ao ser ouvido em Juízo, Kelvin confessou envolvimento no tráfico de entorpecentes. Declarou que está em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Tudo indica que o réu não teve novo envolvimento na prática de ilícitos desde o ocorrido (02.08.2.020).

Entendo que nesse momento a prisão não favorecerá o acusado, que parece estar em busca de um novo recomeço.

Dito isso e como estão preenchidos, ao menos em tese, os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela de prestação pecuniária, em valor equivalente a um salário mínimo, a ser pago a uma entidade pública ou privada com destinação social, na forma do art. 45, § 1º, do Código Penal, devendo tal local ser indicado pelo Juízo da Execução.

Como a pena fixada é superior a um ano, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, deve esta ser substituída por duas penas restritivas de direitos, ou por uma

pena restritiva de direitos mais uma pena de multa.

Por conseguinte, sem prejuízo da prestação pecuniária, substituo a pena privativa de liberdade também por uma pena de 10 (dez) dias-multa, a ser aplicada cumulativamente àquela fixada no tipo penal.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no dia dos fatos, corrigindo-se em sede de execução, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06.

Fixo desde o regime aberto para o cumprimento de pena tendo em vista que a sanção aplicada é inferior a 4 (quatro) anos e o réu é primário, tudo em consonância com disposto no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR KELVIN LUAN DOS SANTOS BEZERRA, RG nº 55.270.518, CPF nº 554.777.898-24, filho de Paulo Gomes Bezerra e de Tereza Maria dos Santos, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, ser cumprida inicialmente no regime aberto, que é substituída por uma pena restritiva de direito, qual seja, uma pena de prestação pecuniária em valor equivalente a um salário mínimo, e por uma pena de 10 (dez) dias-multa.

Kelvin poderá apelar em liberdade, pois é primário e ostenta bons antecedentes.

Ademais, nada justifica a decretação da prisão preventiva do réu.

Transitada em julgado esta sentença, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Declaro o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida em poder de Kelvin, pois comprovadamente proveniente do tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06 (fl. 108).

Concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Varzea Paulista, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA